

1501304-03.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501304-03.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501304-03.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALEX SANDRO RIBEIRO LOPES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ALEX SANDRO RIBEIRO LOPES, qualificado à fl. 58, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de janeiro de 2022, durante o período noturno, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Mais Você, situado na Rua Professor Noé Azevedo, nº 921, Jardim Cedral, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, o DENUNCIADO, agindo em concurso de pessoas com indivíduo não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si,

coisas alheias móveis, consistentes em 10 (dez) caixas de cerveja em lata, 10 (dez) caixas de vinhos espumantes, 10 (dez) caixas de refrigerantes, 10 (dez) pacotes de cigarros com 10 (dez) unidades) e uma caixa de isqueiros com 24 (vinte e quatro) unidades, consoante boletim de ocorrência de fls. 04/05 e laudo pericial do local dos fatos de fls. 40/43, sendo os bens avaliados em R\$ 2.409,00 (dois mil, quatrocentos e nove reais - fl. 60), em prejuízo da pessoa jurídica acima mencionada, representada por Jacqueline Aparecida Bertato Sanches. Ao que consta dos autos, o denunciado reside próximo ao supermercado retro mencionado e é egresso do sistema prisional em data recente. No dia dos fatos, com a finalidade de subtrair bens, o denunciado se uniu com terceiro não identificado e se dirigiu ao estabelecimento comercial. Aproveitando a ausência de pessoas no local proporcionado pelo repouso noturno, romperam o cadeado que guarnecia o depósito e adentraram o local. Em seguida, subtraíram diversas caixas de cervejas, vinhos, refrigerantes, cigarros e isqueiros, citados acima, e deixaram o local levando-os consigo e consumando o delito. No ano de 2020 e no dia 24 de fevereiro de 2022 o denunciado também foi surpreendido subtraindo bens do mesmo estabelecimento, consoante ocorrências policiais de fls. 06/13. A res furtiva não foi recuperada.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 108/109, de 29 de abril de 2022, tendo o réu após regular citação ofertada defesa preliminar (fls. 118/119), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 124) e o despacho de fls. 125/128, de 1º de junho de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 235/236) pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia, ante a prova dos autos, bem como a reparação dos danos à vítima. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 235/236), pediu, em resumo, a absolvição do réu quanto a autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, especialmente pela palavra da vítima, que a princípio disse reconhecer o réu por seu cabelo, todavia, se contradisse em Juízo. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, já que nem todos os objetos foram apurados nestes autos, tendo a vítima mesma, dito que foi subtraídos bens em datas distintas, nesta data tendo dito que foi subtraído cigarros e isqueiros, reconhecendo a atipicidade material da conduta, absolvendo o réu nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal em regime aberto para cumprimento da reprimenda. É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade do delito narrado na denúncia é imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de avaliação de fls. 60; pelo laudo pericial de fls. 40/43, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em Juízo, a testemunha Marco Aurélio Valcazara Camargo, policial civil, declarou que depois da ocorrência foi-lhe passado as investigações e em contato com a proprietária do estabelecimento que lhes forneceu as imagens das câmeras de segurança, e a partir daí, após as diligências realizadas, conseguiram chegar a pessoa Alex Sandro. Tentou contato com Alex Sandro que compareceu na Delegacia de Polícia, e mostrada as imagens das câmeras, ele admitiu a autoria do delito. Afirma que o réu disse que teve a participação de outra pessoa, mas não quis dizer quem era, talvez chamado de moringa ou coringa. Após alguns dias, foi atrás dessa pessoa, e a mãe dele disse que é usuário de drogas e costuma praticar crimes na

região. Afirmar ter visto as imagens das câmeras, mas não se lembra se a pessoa estava de rosto limpo ou encoberto, mas pelas características físicas obtidas da filmagens e informações chegaram a conclusão que o réu Alex era o autor do delito. Com o réu nenhum objeto foi encontrado.

O réu não foi interrogado, porque, regularmente intimado (fl. 230), injustificadamente deixou de comparecer, tendo então, sido decretada a revelia (fl. 235), encerrando-se a instrução processual.

Porém, em solo policial, Alex Sandro Ribeiro Lopes, admitiu que ingressou no estabelecimento comercial acompanhado de outra pessoa, estando sob efeito de drogas, acabando subtraindo produtos do mercado. Disse que o portão do local estava aberto e que forçou a porta para ingressar no interior do mercado. Nega que tenha passado pelo telhado e de ter danificado a janela. Disse que subtraiu cigarros, colocando numa sacola e deixando o local, após trocou tudo por droga. Já tinha sido preso anteriormente por ter furtado cigarros no mesmo local. Disse não sabe qualquer qualificação da outra pessoa que lhe auxiliou no furto, dizendo apenas que o conhece como "Moringa".

No caso, estando a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório. Nesse sentido: A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 'O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram' (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. Em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil." (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de corréu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Robustecendo a palavra do réu quando prestou seu depoimento na Delegacia de Policial, o investigador Marco Aurélio disse que de posse das imagens das câmeras de vigilância, conseguiu descobrir que aquela pessoa era Alex Sandro Ribeiro Lopes. Disse que contatou o réu que compareceu espontaneamente na Delegacia e deu sua versão dos fatos, que após isso, tentou identificar o terceiro que o acompanhou na empreitada criminosa, mas sem sucesso.

Não é demais lembrar que depoimentos de policiais, civis ou militares e agentes penitenciários, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha,

principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Confira-se:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes" (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 223086/SP DJe 02/12/2013).

"Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)" (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5ª Câmara Criminal Apelação nº 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).

Nesse ponto, "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278). Nos autos há prova suficiente e segura a demonstrar não só a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, mas também a autoria deles pelo réu e de que inexistente qualquer causa que possa levar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, entretanto, há importantes considerações a se fazer.

A res furtiva não foi localizada, todavia, não há como imputar ao réu a subtração de todos os objetos descritos na denúncia, pois, além de ser impossível ter carregado 50 fardos de cerveja, 10 garrafas de refrigerantes de 2 litros cada, 3 caixas de vinha com 6 unidades, não parece condizente com a condição que foi descrita por ele no seu depoimento perante a Autoridade Policial, quando disse estar sob efeito de drogas, porém, conforme ele próprio admitiu, os maços de cigarro e os isqueiros, não resta margem para dúvidas de ter sido ele o autor da subtração.

Não há como admitir que o furto seja socialmente tolerado porque subtraído bem de pequeno valor (auto de avaliação de fls. 60) ou porque a vítima não teve prejuízo financeiro com o crime. Pelo contrário, o próprio réu Alex admitiu que já furtou outras vezes o mesmo estabelecimento, causando outros prejuízos a empresa vítima. Essa conduta exige pronta repressão estatal, uma vez que perceptível a gravidade desse proceder, exigindo-se submissão dos autores dessa espécie de conduta à sanção penal seja para realização dos valores sociais, bem como para adequada aplicação da lei e restabelecimento da ordem jurídica, abalada pelo comportamento considerado criminoso.

Na verdade, a invocada atipicidade em razão do princípio da insignificância seria causa supralégitima de exclusão de ilicitude. Todavia, é de duvidosa caracterização, ainda que se trate de bem de valor reduzido ou ausência de prejuízo financeiro à vítima diante da restituição do bem.

"Não há falar em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto. O valor da res não é ínfimo - sob o enfoque dos destinatários da norma - e devem ser levadas em consideração, sem dúvidas, as condições pessoais do acusado, reincidente. Hipótese em que o reconhecimento da bagatela importaria em verdadeiro estímulo ao crime. A incidência do Direito Penal dá-se em relação ao criminoso, à vítima e à sociedade, motivo por que a particular relação entre os dois primeiros não é a preponderante nos crimes de ação penal pública e não determina o que seja ínfimo ou bagatela. Sem dúvidas é um verdadeiro absurdo cingir-se o conceito de significância unicamente ao monetário quantum correspondente ou à ausência de efetivo prejuízo diante da restituição dos bens. É a coroação da valoração financeira estanque que, infelizmente, prepondera e infecta os valores de nossa pobre sociedade atual e começa a invadir as instituições. Reconhecimento da relevância penal da conduta." (Apelação Crime Nº 70054854203, Sétima Câmara

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 25/02/2014).

"Não há falar-se em atipicidade da conduta. O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do denominado princípio da insignificância. Basta rememorar o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que faz referência ao "pequeno valor" da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa. Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem subtraído é diminuto. Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão veiculada na impetração. Aliás, não se pode olvidar que a aludida causa de exclusão da tipicidade é supralegal, de sorte que há corrente jurisprudencial que não a reconhece. Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara: "Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime de bagatela, posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído ser considerado, para os fins penais, como sendo infimo ou desprezível."(TJSP - 14ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. Ap. Crim. nº 990.08.089790-0, j. 05.03.2009, v.u.).

"...Também, não é caso de absolvição por atipicidade da conduta, diante da adoção do princípio da insignificância. Ora, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age infringe a lei penal, violando uma regra básica de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que não muito valiosas ou de pequeno valor. O furto é crime contra o patrimônio e, por isso, a coisa subtraída precisa ter algum valor econômico. Mesmo que considerado pequeno o valor da res, o que importa neste e em todos os casos semelhantes é o desvalor da conduta praticada pelo agente, a qual é típica, pois prevista na legislação penal em vigor como crime de furto. Portanto, a subtração de bens, mesmo que de pequeno valor, "não pode ser tida como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social" (STJ Resp828181/RS - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU 6.8.2007, p. 654; HC 53139/PB - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJU 26.11.2007, p. 249). Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa que cabe ao legislador, é o resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. Portanto, subtrair coisa alheia móvel, segundo a legislação em vigor, continua sendo crime de furto, dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o juiz, principalmente, não pode ignorá-la negando-lhe aplicação.

A previsão de sanções leves para crimes leves, ou a exclusão do crime por atipicidade da conduta, são tarefas que cabem exclusivamente ao legislador, que vem se desincumbindo de seu papel, como fez ao criar a figura do "crime de menor potencial ofensivo", prevendo o reconhecimento de "crime privilegiado", permitindo a substituição da pena corporal por restritiva de direito etc.

Para Claus Roxin, o primeiro a falar no princípio da insignificância, "o Direito Penal não deve se preocupar com condutas incapazes de lesar qualquer bem jurídico porque se a finalidade da lei penal é tutelar um bem jurídico, quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível, não será possível proceder-se ao enquadramento por absoluta falta de correspondência entre o fato descrito na lei e o comportamento iníquo realizado. Assim, os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos" (in "Curso de Direito Penal", de Fernando Capez, Saraiva, 2000, vol. 1, pág. 16).

Segundo os léxicos, "a expressão "insignificante" é sinônima de bagatela.

Insignificante é o que nada significa que não tem valor, é coisa sem importância, inútil. A expressão "nada" quer dizer coisa nenhuma, não existente, de nenhum valor, vã, nula. (Constituição Federal dicionários Aurélio, Houaiss, Mirador, Silveira Bueno).

Pois então, no caso em apreço, constata-se que não se trata da subtração de coisa insignificante; não se trata de um palito de fósforo, de um alfinete usado, de um

prego, mas de 10 pacotes de cigarros, contendo 10 maços cada pacote, além de isqueiros (1 caixa com 24 unidades).

O valor total dos bens foi estimado em R\$ 684,00 (AUTO DE AVALIAÇÃO DE fls. 60). Portanto, não se pode dizer insignificante o crime praticado pelo réu.

Por derradeiro, caso o pequeno valor da res furtiva leve, sempre, à aplicação da insignificância e ao reconhecimento da atipicidade penal, não haverá tutela jurídica ao patrimônio de estabelecimentos comerciais que trabalham com miudezas, com armarinhos, ou seja, “lojinhas de turco”.

Nesse teor a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser conferido o seguinte precedente: RHC6. 319/PR, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 23/06/97, p. 29.166.

E faz-lhe coro vultosa jurisprudência: RT 587/428, 602/342, 703/351, 723/674, 728/614, 743/673 e 746/622”...(TJSP 4ª Câmara Criminal Rel. Des. Euvaldo Chaib Ap. Crim. nº 0040857-21.2012.8.26.0050 j. 25/02/14).

Há de se considerar a insignificância ou bagatela, em um processo hermenêutico que dependa de se levar em conta outros fatores que não se adstringem à mera subsunção formal do comportamento humano ao tipo penal. Ocorre que a norma tutela bens jurídicos para coibir condutas proibidas dos agentes, o que legitima a norma apenas se tiver ela como escopo impedir uma lesão concreta a um bem jurídico.

Os antecedentes criminais do réu, não de forma isolada, mas analisados em conjunto com todo o arcabouço jurídico trazido aos autos, revela ser impossível também o reconhecimento da atipicidade da conduta àquele que possui antecedentes, principalmente, aqueles que já responderam a outros crimes contra o patrimônio, de modo que o réu reincidente ou de reiteração de condutas, assim decidiu o C.

Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos” (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016). 2. Ademais, no caso, a res furtiva foi avaliada em R\$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (julho de 2020 – R\$ 1.045,00), situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 620.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pela d. Defensoria Pública em favor do réu, não merecem prosperar, tanto pelos motivos expostos, que demonstram firmemente a prática do crime, bem como não há como acolher, igualmente, a desclassificação para o furto simples e o reconhecimento do pequeno valor da res furtiva, impossível tal reconhecimento no presente caso.

De outro norte, a prova oral é farta e suficiente, além de sustentar o desate condenatório, presta-se para comprovar a qualificadora, não obstante inexista laudo pericial confirmando o arrombamento ou rompimento do obstáculo.

Ora, consabido que a ausência de perícia no local ou objeto do crime não é circunstância impeditiva do reconhecimento da indigitada qualificadora, se esta resta demonstrada por outros elementos de prova.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

“RECURSO ESPECIAL, PENAL, FURTO, QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora, prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento das testemunhas. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido” (STJ – Resp 809912/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 05.06.2006, p. 316).

“HABEAS CORPUS. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTACULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA.

INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. A falta de perícia visando à constatação de rompimento de obstáculo

para alcançar a res furtiva não é motivo para afastamento da qualificadora, visto que a circunstância pode ser provada por outros meios. Habeas corpus a que se denega a ordem" (STJ - HC 39754/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 06.02.2006, p. 343). No caso em tela, a prova oral foi capaz de suprir tal ausência, mormente porque, além da vítima, o próprio réu Alex Sandro confirmou que forçou uma porta nos fundos do mercado e a arrombou, em que pese a vítima ter dito que possivelmente o réu tenha entrado pelo telhado.

E, se a prova oral é bastante para configurar o rompimento de obstáculo, certamente se faz suficiente para validar a comparsaria, exaustiva e inarredavelmente evidenciada nos autos, tanto que sequer explicitamente combatida pela defesa. Há que se reconhecer, ainda, o concurso de agentes, restando comprovada aos autos pelo robusto conjunto probatório. A testemunha foi clara ao relatarem que eram dois os indivíduos que cometeram o delito de furto no referido estabelecimento, confirmado pelo réu em seu depoimento, que disse estar acompanhado de pessoa conhecida como Moringa.

Nesta diretriz: "Qualifica o crime de furto ter sido ele praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, o que denota maior periculosidade dos concorrentes. Não exigindo a lei que o crime seja executado por duas ou mais pessoas, configura-se a qualificadora mesmo que, havendo partícipe, a fase executiva fique a cargo de apenas uma pessoa" (Código penal interpretado / Julio Fabbrini Mirabete / Renato N. Fabbrini 6. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007). Em contrapartida, a causa de aumento de pena do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, há de ser rejeitada, em pese posicionamento deste magistrado em sentido contrário.

Segundo novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reexaminando entendimento anteriormente consolidado derivado de interpretação do direito infraconstitucional, adequando-se a novas realidades, confirmou precedente no Tema 1087, em que a figura da causa de aumento de pena do repouso noturno no crime de furto, passa a ser reconhecida somente nos casos de furto simples, previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal, senão vejamos a decisão que trago à colação: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. (IM)POSSIBILIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4º). 2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ." (ProAfr no REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 19/4/2021.).

Como visto, os elementos acima salientados são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que o acusado praticou o crime descrito na denúncia e que tinha a intenção de subtração.

Mencione-se que o artigo 239, Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (in Processo Penal, 2ª ed., Atlas, 1992, Júlio Fabbrini Mirabete, p. 305).

Nesse prisma, em recente julgado, decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A propósito das provas indiciárias, faço coro às lições do Des. Mariano Siqueira, do tempo em que judicava neste Tribunal de Justiça, especificamente por ocasião do julgamento, em 23.10.2006, da Apel. criminal n. 00902129.3/6-0000-000, na 2ª Câmara do 1º Grupo da Seção Criminal, que assim predicava, conclusões aquelas que também cabem no caso em comento, verbis: "(...) a respeito do inexcedível valor probante que os indícios podem apresentar, em certos casos, como o presente, são oportunas algumas lições doutrinárias. Para CHRISTIANO JOSÉ DE ANDRADE, indício vem do latim

indicare, que significa indicar, apontar, mostrar com o dedo ou por meio de um sinal qualquer, demonstrar, revelar. Os escritores mais antigos chamavam os indícios de "testemunhas mudas". Com maestria, realçou MITTERMAYER: "O indício é um fato em relação tão precisa com outro fato que, de um, o juiz chega ao outro por uma conclusão natural. É preciso, então, que haja na causa dois fatos, um verificado, e outro não provado, mas que se trata de provar raciocinando do conhecido para o desconhecido".

Consoante se aqilata do teor do art. 239 da codificação penal adjetiva, considera-se indício a circunstância conhecida e provada (in casu: fatos suso declinados) que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outras circunstâncias (na espécie; o homicídio), extraídas da experiência técnica ou comum. Destarte, pelos indícios, por presunção hominis, vai-se do fato indiciário - através de operação lógica - ao fato a ser provado, segundo os princípios da razão (id quod plerumque accidit), segundo remarcam ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES e ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, in "As Nulidades no Processo Penal", Malheiros Editores, 1992, pág. 133. Pela prova indiciária, em outras palavras, alcança-se determinada conclusão sobre um episódio através de um processo lógico construtivo, estabelecendo-se o devido nexo de causalidade. Os indícios, desta sorte, constituem modalidade indireta de prova e diferem da prova direta porque, nesta, o fato probando obtém silhueta e contornos instrutórios imediatos, apresentando-se, como perlustra MAGALHÃES NORONHA, "diante de nós, sem necessidade do processo lógico-construtivo, porque se nos revela através do testemunho, confissão, perícia, etc...". Em suma, os indícios são igualmente importantes para respaldo e embasamento de uma sentença de preceito condenatório (RT 401/285, 555/114, 722/462), principalmente quando afastam qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 110/127, 214/61, 218/96, 395/309 e 401/285)" (TJSP - Apelação nº 0007203-36.2012.8.26.0505. Rel. Roberto Solimene, j. em 26.02.2014).

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilatado na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória, desclassificatória e atipicidade subjetiva da conduta por ausência de dolo.

Conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação.

Passo a dosagem da pena.

A Folha de Antecedentes Criminais e a Certidão Estadual de Distribuição de Processos fls. 72/101, demonstra que é o réu, possuidor de péssimos antecedentes, de modo que o Processo (fls. 73 - Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0013334-28.2014.8.26.0482 Situação: Suspenso. 02/10/2014 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: dois anos, oito meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 12 dias. Valor da multa R\$ 289,60) 13/10/2014 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 07/11/2014 Recurso Interposto 06/08/2015 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: dois anos, oito meses e vinte dias; Regime: Semiaberto; Multa de 12 dias. Valor da multa R\$ 289,60;) 03/09/2015 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 20/11/2015 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 09/04/2018 Pena cumprida ou julgada extinta (Por Ofício recebido da VEC da comarca de Tupã/SP em 09/04/2018), posto que anteriormente condenado por furto a pena de prisão e sentença transitada em julgado, servirá para aferição dos maus antecedentes.

Na dosagem da pena, na primeira etapa levo em consideração os maus antecedentes do réu, fixando a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), ou seja, 2 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e a pagar a multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda etapa, pela agravante genérica da reincidência específica (fls. 73 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais. Execução da Pena: 0009692-47.2020.8.26.0996 (1500084-26.2020.8.26.0583). 25/01/2020 Data do Fato (Art. 155 § 4º, I do(a) CP Local: RUA PROFESSOR NOÉ AZEVEDO, 921 JD CEDRAL -

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 19067360) 25/01/2020 Prisão (Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: Seccional - Presidente Prudente) 25/01/2020 Decretação da prisão preventiva 25/01/2020 Término da Prisão 25/01/2020 Prisão (Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória " Tácio Aparecido Santana" de Caiuá) 13/07/2020 Progressão de Regime (Regime: Semiaberto -> Semiaberto) 28/08/2020 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, I do(a) CP; Reclusão: dois anos e quatro meses; Regime: Fechado; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 380,97; Situação: Reincidente doloso;) 04/09/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 08/09/2020 Recurso Interposto 26/10/2020 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 155 § 4º, I do(a) CP; Reclusão: dois anos e quatro meses; Regime: Fechado; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 380,97; Situação: Reincidente doloso;) 09/12/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 17/12/2020 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 16/07/2021 Progressão de Regime (Regime: Semiaberto -> Aberto) 16/07/2021 Audiência Admonitória - Regime Aberto), conforme dispõe o artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 1/6 (um sexto), e mais 1/6 (um sexto) pela qualificadora do concurso de agentes, previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, esta, compenso com a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

E, ausentes outras causas que possam modificar a pena, torno-a definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa, cada dia no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Impossível a substituição da pena corporal acima fixada por pena restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena por ser o réu reincidente específico e portador de péssimos antecedentes.

Ante a qualidade de reclusão da pena corporal e a condição de reincidente e possuidor de péssimos antecedentes criminais, inclusive já cumpriu pena pelo mesmo crime, iniciará ela, o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu ALEX SANDRO RIBEIRO LOPES, RG: 30577181, nascido em 12/05/1980, natural de Presidente Prudente - SP, filho de ANTONIO SEBASTIAO LOPES e ISABEL RIBEIRO LOPES, a cumprir a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado; pagar a multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa, cada dia no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 155, §4º, inciso I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Em liberdade durante todo o processo, agora, concedo a ré o benefício de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que interpor contra esta sentença. Após a ocorrência do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA